

1502774-14.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Juliana Nobrega Feitosa

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... mercantil, a condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida de rigor.

Passo à aplicação da pena.

A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando ligada tanto às particularidades fáticas do caso concreto quanto às especificidades subjetivas dos agentes. No crime de tráfico de drogas, a expressa dicção legal do artigo 42 da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Foro de Franco da Rocha

Vara Criminal

Praça Ministro Nelson Hungria n.º 01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502774-14.2021.8.26.0544 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital n.º:

1502774-14.2021.8.26.0544 - Controle n.º 2369/2021

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2308672/2021 - DEL.POL.FRANCO

ROCHA, 21353564 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 3616/21/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2308672

- DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME BARBOSA DE ANDRADE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Nobrega Feitosa

Vistos.

GUILHERME BARBOSA DE ANDRADE, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções cominadas no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 11 de novembro de 2021, por volta de 11h26min, na Avenida Jaci, 173, Jardim Santa Filomena, nesta cidade e comarca, estaria guardando e traria consigo, para supostos fins de entrega a terceiros, as seguintes drogas: 127 papelotes de maconha, pesando, aproximadamente, 317g; 224 porções de cocaína, pesando,

aproximadamente, 241g e 89 pedras de crack, pesando, aproximadamente 49g; substâncias causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da apreensão da quantia de R\$ 11,00 (onze reais) em dinheiro, nos termos da denúncia de fls. 58/59.

A denúncia foi recebida em 22 de novembro de 2021 (fl. 60). O réu foi citado (fls. 72/73), tendo sido apresentada resposta à acusação (fls. 76/77). Ante a ausência de hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (fl. 79), realizou-se a instrução criminal, na qual foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum e, após, o réu foi interrogado. Em alegações orais, o Ministério Público, inicialmente, requereu o reconhecimento da legalidade da prisão em flagrante efetuada pela guarda municipal, assim como requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, requerendo a aplicação do regime fechado e a não incidência da minorante prevista no artigo 33, 4º, da Lei n.º 11.343/06, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, ante seus antecedentes. Por sua vez, a Defensoria Pública pleiteou, resumidamente, ocorrência de preliminares ao mérito, atinentes à ilicitude das provas, assim como requereu sua absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, e, supletivamente, a aplicação da pena privativa de liberdade em seu mínimo legal, em regime diverso do fechado.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, verifico a inexistência de quaisquer nulidades, bem como não ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal, pelo que passo à apreciação do mérito.

Entretanto, insta salientar que a legalidade da prisão do acusado já foi devidamente fundamentada quando da realização da análise do flagrante delito (fls. 39/42). Entretanto, ainda que se sustente a ilegalidade da prisão, em decorrência de provas ilícitas (patrulhamento preventivo efetuado pela guarda municipal), neste caso urge salientar que houve a incidência do flagrante compulsório, ante à constatação fortuita de sua ocorrência, conforme se depreende do que restou apurado.

Nesta linha, já decidiu o STJ que,

“Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexiste óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes” (RHC 94.061/SP, j. 19/04/2018).

Portanto, inobstante a atribuição constitucional da guarda municipal, autoriza-se a este efetivo do Poder Público a prisão daqueles que se encontrem em flagrante delito. Ademais, no caso, os guardas municipais estavam diante de uma situação de flagrante, havendo razão concreta para agir, na medida que presenciaram o réu, naquele exato momento, em atitude traficância. Daí, afasta-se a ilegalidade da prisão sustentada pela Defesa.

A materialidade delitiva se encontra consubstanciada no boletim de ocorrência de fls. 04/07, no auto de exibição e apreensão de fls. 14, no laudo de constatação provisória de entorpecentes de fls. 16/21, no laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 106/108, bem como na prova oral coligida.

Também não há dúvidas no tocante à autoria.

O acusado, em solo policial (fl. 10), disse “ter saído de sua residência em direção

à casa de um amigo, pois planejava consumir junto a ele 'um baseado'. Admite, pois, ser usuário de entorpecentes, negando, entretanto, exercer a prática da traficância. Alega, então, que a guarnição da Guarda Civil Municipal, ao vê-lo caminhando às proximidades de um local notoriamente conhecido como ponto de tráfico de drogas, efetuou a sua abordagem de forma inadvertida, para só depois, já a uma longa distância do local onde foi abordado, encontrar um pacote repleto de entorpecentes, cuja posse nega veementemente. Instado, nega ter sofrido qualquer tipo de agressão ou abuso por parte dos policiais que efetuaram a sua prisão. Afirma ostentar antecedentes criminais referentes à prática do crime de tráfico de drogas, sendo, pois, reincidente. Entretanto, aduz não possuir vínculo com organização criminosa. Alega, ainda, possuir ocupação lícita e residência fixa. Nega, ademais, possuir advogado e indica MARIA DE LOURDES BARBOSA DE ANDRADE, sua mãe, a fim de que seja, nos termos do art. 306 do Código de Processo Penal, imediatamente comunicada a respeito de sua prisão. Relata, finalmente, possuir 1 filho, de 4 anos de idade, o qual convive com a sua mãe (cujo contato o indiciado não soube fornecer)".

O acusado, em juízo, negou a autoria delitiva, informando que na data dos fatos estava em sua casa e saiu para ir até a casa de seu amigo; quando ia entrar na casa de seu amigo, os guardas municipais o abordaram, dizendo a ele que já o teriam visto e filmado na "boca de fumo". Negou os fatos aos guardas, informando que era trabalhador. Disse que o tiraram de dentro da casa de seu amigo, o algemaram e o levaram a uns 300 metros do local. Disse que os guardas municipais iniciaram uma busca com os cães pelo local; que eles encontraram drogas numa sacola, mas nega que seriam suas. Disse que seu amigo não foi para a delegacia. Disse que seu amigo se chama "Cris" e mora na Rua Jaci, não sabendo informar o nome completo de seu amigo.

A autoria encontra-se cabalmente demonstrada, já que o cotejo probatório aponta o acusado como autor da prática criminosa, conforme depoimento das testemunhas.

Com efeito, o guarda municipal Alexsandro Carlos Costa, ouvido em delegacia à fl. 08, declarou que "a equipe estava em deslocamento, quando, ao avistar um indivíduo que se portava de maneira suspeita, decidiu efetuar a abordagem. Com efeito, ao aproximar-se, a guarnição notou que o indivíduo tentou empreender fuga, dispensando, no ato, um pacote. Alcançando-o, o identificaram como GUILHERME BARBOSA DE ANDRADE e constataram haver no interior do pacote recuperado pela equipe o equivalente a: a) 127 (cento e vinte e sete) porções de substância similar à maconha; b) 224 (duzentas e vinte e quatro) porções de substância similar à cocaína; c) 89 (oitenta e nove) pedras de substância similar ao crack; e d) R\$ 11,00 (onze reais) em notas de pequeno valor. Em vista da natureza proscrita, bem como, dada a quantidade e variedade dos entorpecentes e a forma de acondicionamento, em pequenas porções, o escopo de distribuição no varejo, indício reforçado pela apreensão também de numerário, deduzido produto do comércio ilícito, mormente porque trocado, a guarnição decidiu encaminhar o indivíduo à presença da autoridade policial". No mesmo sentido foram as declarações do guarda municipal e testemunha Wagner Aparecido de Santana Leite, ouvido em delegacia à fl. 09.

Em juízo, as testemunhas Alexsandro e Wagner foram uníssonas em informar que a equipe estava em patrulhamento pelo local, quando, em dado momento, ao apresentar atitude suspeita (nervosismo), se aproximarem do acusado, indo de encontro a ele; ao perceber a presença da viatura, Guilherme dispensou um pacote que portava e tentou fugir em passos rápidos, mas conseguiram abordá-lo. Na sacola deixada por Guilherme havia drogas. O endereço do local dos fatos é Rua Jaci, no município de Franco da Rocha. O pacote era preto. No momento da dispensa da droga só havia o acusado no local.

Diante destes elementos de provas coletados em juízo, em observância às circunstâncias em que ocorreu a prisão do denunciado, tais situações, em conjunto revelam a prática incontestável do delito tipificado na denúncia consistente na

prática do tráfico ilícito de drogas. A versão apresentada pelo acusado é distorcida de todo o conjunto probatório e sequer sabe apontar o nome de seu suposto amigo, quando de sua abordagem, o qual serviria como testemunha de defesa.

Com relação aos trechos dos depoimentos acima apontados, os quais foram prestados em juízo por guardas municipais, faz-se importante consignar que suas declarações devem ser apreciadas como as de qualquer cidadão, tanto que podem responder igualmente por falso testemunho.

Em razão disso, não se demonstrando que o funcionário público tenha mentido ou que exista fundado motivo para tanto, não há que se cogitar de inviabilidade de seu testemunho.

O depoimento testemunhal de servidores da força pública somente não terá valor se evidenciar que o funcionário do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstre que suas declarações não encontram suporte, licitude, legalidade e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios.

Sob este aspecto, verifico que os depoimentos coletados em juízo são coerentes e harmônicos entre si, estando de acordo com as demais provas existentes, razão pela qual, à míngua de qualquer alegação de suspeita tempestiva, encontram-se revestidos de suficiência para embasar o decreto condenatório.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, firmado em tese, afirma que “é válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou responsáveis por prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais provas dos autos e for colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. (Jurisprudência em Teses do STJ EDIÇÃO N. 105: PROVAS NO PROCESSO PENAL – I)

Não há dúvidas, ainda, acerca da destinação de tais entorpecentes, haja vista que as circunstâncias da prisão, aliadas à natureza e à diversidade das drogas que foram apreendidas – quais sejam, 127 papérolas de maconha, pesando, aproximadamente, 317g; 224 porções de cocaína, pesando, aproximadamente, 241g e 89 pedras de crack, pesando, aproximadamente 49g – comprovam, de maneira inequívoca, a finalidade mercantil. Como se não bastasse, o fato de ter sido apreendida a quantia de R\$ 11,00 (onze reais), ao ser considerado em conjunto com as circunstâncias já delineadas, demonstra, de maneira inequívoca, que tal valor era proveniente da mercancia ilícita de drogas.

Consigne-se que, para a caracterização da traficância, a jurisprudência é remansosa acerca da desnecessidade de identificação de qualquer suposto cliente para o qual a droga se destinaria, também não sendo necessário que o agente seja observado ou abordado enquanto praticava atos efetivos de mercancia.

Neste interim, está sedimentado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, sendo curial destacar que, o tipo penal descrito no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla e de natureza permanente, razão pela qual a prática criminosa se consuma, por exemplo, a depender do caso concreto, nas condutas de “ter em depósito”, “guardar”, “transportar” e “trazer consigo”, antes mesmo da atuação provocadora da polícia, o que, no caso dos autos, remanesce o flagrante crime de tráfico de drogas.

O acréscimo punitivo da agravante prevista no artigo 61, inciso I, alínea “j” do Código Penal, como requer o Ministério Público, no caso concreto, é injustificável, na medida em que não relacionado com o maior desvalor da conduta. Não há nos autos prova no sentido de que o réu tenha efetivamente se valido das fragilidades ocasionadas pela pandemia para delinquir, sob pena de responsabilização objetiva.

Portanto, inexistente qualquer relação entre a prática delitiva e os efeitos da calamidade pública, despropositada sua aplicação.

Por estarem comprovadas, portanto, autoria e materialidade delitivas, bem como o fato de que as substâncias entorpecentes apreendidas tinham destinação mercantil, a condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida de rigor.

Passo à aplicação da pena.

A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando ligada tanto às particularidades fáticas do caso concreto quanto às especificidades subjetivas dos agentes. No crime de tráfico de drogas, a expressa dicção legal do artigo 42 da lei 11.343/2006 determina ao juiz, quando da fixação das penas, considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, que podem permitir o aumento da pena-base do condenado.

Atendendo às disposições constantes do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, bem como ao critério trifásico previsto no artigo 68, do Código Penal, verifico que o acusado, embora registre outro processo em sua folha de antecedentes (certidão de fls. 93/94) permanece primário. A quantidade das drogas apreendidas em seu poder, por seu turno, não habilita a majoração da pena-base. Assim, ante sua primariedade, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.

Não há quaisquer circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas na segunda fase da aplicação da pena, ante o teor da Súmula 231 do STJ, apesar de sua menoridade relativa, a qual não pode ser considerada, tendo em vista o entendimento majoritário do STJ (Resp 1.117.073/PR e Resp 1.117.068), ressaltando o entendimento diverso deste juízo, porém acatando a decisão do E. Tribunal Superior, a fim de dar cumprimento à racionalidade das decisões do Poder Judiciário.

Cumprе consignar que o acusado não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, ante a quantidade de pena aplicada, bem como a substituição é inadequada e insuficiente para a reprovação e a prevenção do delito, haja vista que o acusado ostenta diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude (fl. 92), por prática de atos infracionais enquanto menor, evidenciando a dedicação às atividades criminosas, o que afasta o privilégio no tráfico de drogas por falta de preenchimento dos requisitos cumulativos enumerados no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas.

O réu iniciará o cumprimento de sua pena no regime FECHADO, em obediência aos parâmetros contidos no artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal e no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90, uma vez que, embora a pena fixada não seja superior a oito anos, tal regime é o único recomendável ao caso dos autos, ante a elevada culpabilidade de agentes que cometem tráfico ilícito de entorpecentes, e se encontra em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (artigo 5º, inciso XLIII).

Ainda, atendendo a nova redação do art. 387, § 2º, CPP, dada pela lei 12.736/12, mantenho o regime FECHADO, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, uma vez somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena. Não se pode, dessa maneira, vincular à progressão de regime um mero procedimento de cálculo aritmético de cumprimento de pena, ignorando o mérito do sentenciado e, verdadeiramente, negando vigência ao que estabelece o art. 112 da Lei de Execução

Penal, que não se encontra revogado. Ademais, ainda que assim não fosse, observo que, embora se possa saber o tempo que o réu permaneceu custodiado, não dispõe esta Magistrada de informações seguras sobre a satisfação dos demais requisitos para a detração da pena ou eventual progressão de regime, o que reforça a tese de que a avaliação dos requisitos indispensáveis à concessão desses benefícios somente é possível pelo Juízo da Execução da pena, nada se podendo fazer neste momento do processo.

O valor de cada dia-multa será o mínimo legal, isto é, um trigésimo do salário mínimo vigente no dia do fato, corrigido em sede e executado em sede de execução, nos termos do artigo 49, parágrafo 2º e 51, ambos do Código Penal, por não haver provas nos autos de que o réu possua boa situação financeira.

É incabível a concessão do sursis, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, conforme acima fundamentado.

Do exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA, para o fim de CONDENAR o acusado GUILHERME BARBOSA DE ANDRADE, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, no regime inicial FECHADO, vedadas quaisquer substituições previstas em Lei, bem como à pena de 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, pelo cometimento do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu permaneceu preso durante todo o trâmite processual, o que demonstra que subsistem os requisitos da prisão preventiva, máxime agora, com sentença penal condenatória, não havendo, pois, quaisquer motivos para a concessão de liberdade provisória em seu favor, pelo que não poderá apelar em liberdade.

Nesse sentido:

"É pacífico na jurisprudência que o direito de recorrer da sentença penal condenatória em liberdade não se aplica ao réu já preso em decorrência de flagrante ou de prisão preventiva, que assim permaneceu durante todo o curso da instrução criminal, ou pelo menos grande parte dele.

Confira-se, a respeito, o posicionamento desta C. Câmara, ao decidir questões semelhantes:

'Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória. Pedido de apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Paciente permaneceu sob custódia do Estado durante a instrução processual. Ordem denegada.' (HC nº 0276546-35.2011.8.26.0000, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j. 16/02/2012, V.U.).

'HABEAS CORPUS - Tráfico de Entorpecentes - Regime inicial fechado - Fixado de acordo com a legislação vigente - Apelo em liberdade vedado - Réu que permaneceu preso durante o processo - Não ofensa à garantia constitucional da presunção de inocência - Ordem denegada.' (HC nº 0181659-59.2011.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Marques e Silva, j. 12/04/2012, V.U.).

O C. Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou a respeito, afirmando: 'A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal.' (RHC nº23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008).

Deveras, não haveria qualquer lógica em manter o acusado preso durante a instrução e, sobrevindo condenação, ainda que não transitada em julgado, soltá-lo para aguardar o julgamento da apelação interposta. Ao contrário, a prolação de sentença condenatória reforça e ratifica o cabimento da prisão. Assim, não se caracteriza, aqui, medida desproporcional que revele o alegado constrangimento do paciente."

(Habeas Corpus nº 2055783-89.2013.8.26.0000 - 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo - Relator De Paula Santos - julgado em 27 de março de 2014 - votação unânime).

Recomende-se o réu no local em que se encontra preso, comunicando-se a alteração da natureza de sua custódia.

Condene o acusado ao pagamento das custas processuais, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que nesta oportunidade lhe concedo os benefícios da gratuidade da justiça, em razão de ter sido defendido pela Defensoria Pública no presente feito.

Ainda, por se tratar de proventos auferidos com a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, determino o perdimento dos valores apreendidos nos presentes autos, nos termos do artigo 63 e respectivos parágrafos da Lei nº 11.343/06. Oficie-se à autoridade policial para a destinação cabível, nos termos do artigo 516, das NSCGJ.

Providencie-se a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas (artigo 32 e respectivos parágrafos da Lei nº 11.343/06).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franco da Rocha, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA